

1523131-90.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... CPP) com relação às duas imputações de tráfico de entorpecentes e de associação para a prática do tráfico. Subsidiariamente, requereu (ii) a desclassificação do tráfico para o uso de entorpecentes com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06; (iii) fixação da pena base no mínimo legal; (iv) a desclassificação para o delito previsto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523131-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523131-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICASSIO MARINHO DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LORHANY BARBOSA SILVA (certidão de nascimnto a fls. 165); BEBEL SOARES DE SOUZA (nome social de ALISSON SOARES DE SOUZA); NICASSIO MARINHO DA SILVA; SÉRGIO DE SOUZA e TARCÍSIO FERNANDO MOURA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigos 69, caput, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 17:55 hs, no Largo do Arouche, na altura do nº 183, República, bem como no Hotel Dela Rose, situado na Rua Amaral Gurgel, n. 48, quarto 211, Santa Cecília, nesta Capital, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam consigo e tinham em depósito, para fim de tráfico, drogas (cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, ainda, porque em período incerto, no mínimo do início do mês de setembro de 2021 até dia 22 do mesmo mês, na região central desta Capital, especialmente no Largo do Arouche, LORHANY BARBOSA SILVA (certidão de nascimento fls. 165); BEBEL SOARES DE SOUZA (nome social de ALISSON SOARES DE SOUZA); NICASSIO MARINHO DA SILVA; SÉRGIO DE SOUZA e TARCÍSIO FERNANDO MOURA DA SILVA, associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas. De acordo com a denúncia a mercancia em associação contava com a seguinte divisão de tarefas: TARCÍSIO exercia a função de gerente (recebia o dinheiro dos vendedores e entregava as drogas que estavam escondidas em

um canteiro); NICASSIO e BEBEL (ALISSON) exerciam a função de vendedores (recebiam as drogas do gerente, escondiam em suas vestes, entregavam aos usuários e depois retornavam com o dinheiro); SÉRGIO exercia a função de olheiro (observava a movimentação da região para avisar sobre ações policiais).

Abordados, foram encontrados 12 papelotes de cocaína com NICASSIO, 06 papelotes de cocaína com BEBEL (ALISSON) e 05 papelotes de cocaína e R\$ 190,00 em dinheiro com TARCISIO.

Segundo a denúncia, ainda, TARCISIO confessou que trabalhava com LORHANY e indicou o quarto 211, no Hotel Dela Rose, como o local de armazenamento da droga. No local, o funcionário Fagner José dos Santos forneceu a chave do quarto onde os policiais localizaram 60 papelotes de cocaína dentro de uma lata escondida atrás de um móvel na lateral da cama. Em seguida os policiais foram até a residência de LORHANY onde o prenderam em flagrante. LORHANY confessou que fornecia drogas a TARCISIO.

A denúncia foi recebida (fls. 214/216), os réus foram citados e notificados (fls. 277, 278, 286, 329 e 330) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 282/284 - LORHANY, 312 - NICASSIO, BEBEL (ALISSON), SÉRGIO e TARCISIO).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 300 e 312/313), em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada em 23 de março de 2022 e em continuação em 05 de julho de 2022 foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 312/315 e 367/373).

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa de BEBEL SOARES DE SOUZA (nome social de ALISSON SOARES DE SOUZA), NICASSIO MARINHO DA SILVA e SÉRGIO DE SOUZA requereu (i) a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) com relação às duas imputações de tráfico de entorpecentes e de associação para a prática do tráfico.

Subsidiariamente, requereu (ii) a desclassificação do tráfico para o uso de entorpecentes com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06; (iii) fixação da pena base no mínimo legal; (iv) a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/2006 para o réu SÉRGIO; (v) aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; (vi) fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado (semiaberto); (vii) computo do tempo de custódia cautelar para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena; (viii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito para a ré BEBEL; (ix) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 436/455).

A Defesa de TARCISIO FERNANDO MOURA DA SILVA requereu (i) a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) com relação às duas imputações de tráfico de entorpecentes e de associação para a prática do tráfico.

Subsidiariamente, requereu (ii) a desclassificação do tráfico para o uso de entorpecentes do artigo 28 da Lei 11.343/06; (iii) fixação da pena base no mínimo legal; (iv) aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; (v) fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado (aberto); (vi) computo do tempo de custódia cautelar para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena; (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 456/470).

A Defesa de LORHANY BARBOSA SILVA requereu (i) a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, IV, V ou VII, CPP) com relação às duas imputações de tráfico de entorpecentes e de associação para a prática do tráfico. Subsidiariamente, requereu (ii) fixação da pena base no mínimo legal; (iii) direito de apelar em liberdade e (vi) devolução do seu aparelho celular (fls. 482/507).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente em relação aos réus TARCISIO, NICASSIO e BEBEL (ALISSON) para absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação para o cometimento de tráfico e desclassificação com condenação por porte de entorpecente; e, totalmente improcedente em relação aos réus LORHANY e SÉRGIO.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecente em associação estão previstos no Art. 33 (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) e Art. 35 (Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei) da Lei 11.343/2006.

A denúncia imputou que a mercancia em associação contava com a seguinte divisão de tarefas:

TARCISIO exercia a função de gerente (recebia o dinheiro dos vendedores e entregava as drogas que estavam escondidas em um canteiro);

NICASSIO e BEBEL (ALISSON) exerciam a função de vendedores (recebiam as drogas do gerente, escondiam em suas vestes, entregavam aos usuários e depois retornavam com o dinheiro);

SÉRGIO exercia a função de olheiro (observava a movimentação da região para avisar sobre ações policiais).

LORHANY entregava a droga armazenada no quarto 211, no Hotel Dela Rose, para TARCISIO.

Ocorre que as provas produzidas nesses autos, ao contrário do quanto afirmado pelo Ministério Público, não foram suficientes para comprovar os fatos que constaram da acusação. Senão vejamos.

Os elementos de prova que vieram aos autos no sentido de demonstrar a materialidade do tráfico em associação foram o Auto de prisão em flagrante (fls. 3/5), Boletim de Ocorrência (fls. 11/17), Termos de depoimento (fls. 6/7, 8/9 e 10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), Laudo de Constatação da droga (fls. 54/58), Relatório Final (fls. 147/149 e 153) e Laudo toxicológico definitivo (fls. 336/338), Laudo Pericial Descrição de um maço de cigarros (fls. 308/310), Laudo pericial de dois celulares (fls. 303/307).

Também vieram aos autos as filmagens cujo link de acesso está às fls. 58.

Por fim, os depoimentos das testemunhas, que seguem.

O policial civil Maurício de Oliveira Silva discorreu, em síntese, que há uma comunidade na área do bom retiro e havia informações de que alguém buscava droga naquele local e abastecia o tráfico no largo do Arouche, sendo passado o apelido de Lorhany. Foram até o local, em uma viatura descaracterizada e passaram a fazer campana quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Depois perceberam que vendiam algo para terceiros, parecendo traficância. Pediram apoio para outra equipe. Durante a abordagem, localizaram drogas e dinheiro. Disse ter filmado a movimentação. Esclareceu que Sérgio atuava como olheiro, não tendo presenciado ele vendendo as drogas. Esclareceu que somente tiveram contato com Lorhany depois, pois ela não estava no largo do Arouche. Disse que perceberam que Tarcísio pegava dinheiro, ia até uma praça, num matagal, pegava algo e entregava para os demais, mas não ficava com os entorpecentes. Sérgio negou participação no crime. Tarcísio disse que trabalhava para Lorhany. Também indicou um hotel na Avenida Amaral Gurgel, próximo ao Largo do Arouche. Foram até o local, tendo o funcionário os acompanhado, onde localizaram cocaína atrás de um móvel. Tarcísio foi junto até o hotel, tendo sido ele quem indicou onde estava a droga. O funcionário disse que não havia ninguém no quarto naquele momento, mas que era alugado por uma pessoa, a qual somente ia até lá às vezes. Não se lembra se o funcionário declarou o nome de quem alugava o quarto. Tarcísio disse que era Lorhany quem alugava o quarto e não percebeu se ele era conhecido no local. Na praça, encontram drogas com dois dos acusados que vendiam e no local para onde viram Tarciso se dirigindo. Com Tarcísio, encontraram cento e noventa e reais. Tarcísio indicou a casa de Lorhany, bem como a hora que ela chegaria, o que de fato ocorreu. Foram até a casa de Lorhany e ela

confessou, informalmente, a prática da traficância. Não acompanhou o depoimento de Lorhany perante o escrivão de polícia. Não conhecia nenhum dos acusados. A campana no largo do Arouche durou cerca de trinta a quarenta minutos. Na denúncia anônima, disseram que a pessoa que buscava drogas na comunidade era uma pessoa de nome Lorhany e que andava de moto. Não sabe dizer quando foi recebida a denúncia anônima. Não se lembra se foram perguntadas as características da pessoa que alugava o quarto em questão. Não sabe se foi pedido alguma documentação de controle ou câmera do local. Lembra de ter visto um livro, mas não se recorda se leram o nome de Lorhany. Somente falaram com um funcionário. Não entraram na casa de Lorhany, porque já haviam entrado antes no local acompanhados de Tarcísio e nada fora encontrado. Não consegue declinar quantas transações suspeitas avistaram durante a campana, mas acredita ter sido pelo menos quatro ou cinco. Não se lembra se Tarcísio declinou a participação de cada um, mas não era usual que ele tivesse feito, acreditando que ele somente apontou a participação de Lorhany para dizer que a droga não era sua. Lorhany disse que traficava para ajudar Tarcísio que estava com dificuldades financeiras. Não se recorda o veículo pelo qual foi transmitida a denúncia anônima em questão.

Em que pese seu testemunho ter corroborado em boa parte as declarações apresentadas na delegacia (fls. 6/7), necessário destacar desde já que ao contrário do quanto constou no depoimento na polícia, em juízo a testemunha disse não se recordar se o funcionário do hotel declarou o nome de quem alugava o quarto, tendo sido Tarcísio quem afirmara que Lorhany quem alugava o quarto. Ainda, constou do seu depoimento em juízo que a testemunha não pode perceber se Tarcísio era conhecido no local.

Sandro Caetano do Valle, também policial civil, ouvido como testemunha relatou, em resumo, que receberam denúncia anônima de tráfico de drogas no largo do Arouche. Foram até o local em viatura descaracterizada e puderam observar os quatro réus traficando, exceto Lorhany. Constataram, que Tarcísio era o gerente do tráfico e que foi até a praça pegar mais droga guardada atrás de uma mureta, ao passo que Sérgio ficava como olheiro e os outros efetuavam a venda da droga distribuída por Tarcísio. Como eram muitas pessoas, pediram apoio e efetuaram prisão em flagrante dos quatro réus, exceto de Lorhany. Tarcísio confessou a prática da traficância, tendo sido contratado por Lorhany, bem, como que guardavam as drogas no hotel Dela Rose. No hotel, encontraram cocaína onde indicado por Tarcísio. O porteiro reconheceu Tarcísio quando chegaram no local e o funcionário ainda disse que Lorhany não morava no local, mas ia ali esporadicamente. O hotel era muito próximo ao local onde traficavam, servindo como depósito. Feita a abordagem no Largo do Arouche eles foram levados para a Delegacia, a gente perguntando, a gente perguntando e Tarcísio indicou o Hotel. Voltamos para a Delegacia, perguntamos quem era, quem era e Tarcísio deu a Lorhany. Tarcísio indicou também o local de residência de Lorhany e horário que ela costumava chegar. Fizeram campana e na hora por ele indicada, ela chegou. Não ingressaram na casa de Lorhany, ficaram com receio de que ela fosse avisada se falassem com o porteiro. Ela confessou a prática da traficância e relatou ser namorada de Tarcísio. Ficou indignada porque teria levado ele para morar consigo e ele a denunciou. Nada foi mencionado sobre a atuação dos demais acusados pelo Tarcísio, nem perguntou a ele, porque percebeu que era um grupo, pois todos se conheciam e, no tráfico, o modus operandi é formar um grupo e não trocar as pessoas a todo momento para evitar que vazem informações. Nem perguntou a eles. Mostrado o vídeo cujo link está às fls. 58, esclareceu que foi um dos momentos da venda da droga. Diz que aparecem nas imagens é Nicasso e deve ser a Bebel. Declarou ter sido a primeira investigação feita no Largo do Arouche, não tendo havido outras anteriores. Mencionou não ter encontrado nada de ilícito com Lorhany. A informação anônima veio pelo nosso chefe. A denúncia recebida indicava que Lorhany, uma travesti, buscava droga na favela do gato e distribuía no Largo do Arouche. Na denúncia, não havia notícia sobre a distribuição de tarefas. Perceberam que era algo constante, porque pessoas iam direto neles e receberam parabéns de populares quando efetuaram a prisão em flagrante pois diziam que isso sempre acontecia, durante todo o momento. Não arrolaram testemunhas porque já

tinham as filmagens. Declarou que tudo que filmaram foi entregue. Filmaram o que conseguiram apesar de o celular não ter a melhor qualidade. Não se lembra se pegaram a chave do quarto do hotel na portaria ou se Tarcísio a tinha consigo. Foi o depoente quem pegou a droga no imóvel indicado por Tarcísio e não o funcionário, ao contrário do que constou as fls. 09. Não se lembra se foram encontrados papéis de contabilidade.

Em que pese seu testemunho ter corroborado as afirmações que havia prestado na fase investigativa (fls. 8/9) ele entrou em conflito com o depoimento do seu colega policial, especialmente quando Sandro afirmou que o porteiro reconheceu Tarcísio quando chegaram no local e que o funcionário Fagner teria dito que Lorhany quem alugava o quarto, fatos que não foram confirmados por seu colega de ofício.

Ainda a testemunha Fagner, funcionário do Hotel Dela Rose, em pontos centrais o teor de seu depoimento prestado na polícia. Vejamos.

Fagner José dos Santos em solo investigativo as fls. 10, disse: "QUE, informa o depoente que é folguista na recepção do Hotel Dela Rose há aproximadamente três meses, situado na Rua Amaral Gurgel n.º 48, sabendo ainda que o gerente do referido Hotel é conhecido por "João Neto"; QUE, a respeito dos fatos, o depoente prontamente indicou o quarto 211 como sendo de "Lorrani", acompanhando as diligências em referido quarto, onde foram localizados 60 papелotes de cocaína que eram acondicionados em uma lata que estava escondida atrás de um móvel, próximo a cabeceira da cama; QUE, o depoente informa que "Lorrani" paga a diária de R\$ 60,00 para uso do quarto, pagando semanalmente o valor de R\$ 420,00 em espécie; QUE, o depoente informa que "Lorrani" não reside no local, sendo que quando comparece apenas fica por um breve período e sai".

Em juízo, a testemunha Fagner José dos Santos disse, em suma, que não conhece os acusados nem os fatos. Declarou que trabalha como recepcionista no Hotel Dela Rose e que Lorhany estava hospedada no local e que policiais estiveram no local, mas não sabe porque razão foram até lá. Presenciou os policiais encontrando drogas no criado mudo, ao lado da cama. Não sabe que droga foi encontrada. Não observou se havia pertences da ré ou objetos pessoais. A diária custava sessenta reais declarou que era folguista e que trabalhava no local um dia por semana. Há câmeras no estabelecimento, mas a polícia não pediu sua filmagem. Disse que Lorhany morava no hotel, mas era difícil vê-la. O pagamento era diário, na recepção. O controle de entrada e saída e pagamento era feita por anotação em livro. Quando os policiais chegaram, havia um homem detido em companhia dos mesmos. Lorhany não estava no hotel quando da chegada da polícia e do encontro das drogas.

Não bastassem suas informações incongruentes, especialmente quanto à forma de pagamento do quarto 211 e controle deste pagamento, o fato de conhecer ou não Lorhany e se ela morava no local ou não, bem como qual tipo de droga teria sido encontrado no quarto, a testemunha Fagner não procedeu em juízo ou na fase investigativa ao reconhecimento de Lorhany ou de qualquer outro dos acusados.

Também não vieram aos autos, qualquer filmagem do referido Hotel Dela Rose, apesar da informação de existência de câmeras no local.

Também não veio aos autos qualquer cópia do livro de controle de entrada e saída e de pagamento, afirmados como existentes pela testemunha José Fagner.

Quanto aos réus, em que pesem as informações dos policiais quanto as confissões informais, a realidade é que todos, permaneceram em silêncio na fase investigativa (fls. 28, 29, 30, 31 e 32).

E, em seus interrogatórios em juízo, negaram o tráfico e a associação.

Em outras palavras, as confissões informais que teriam levado os policiais até o Hotel e até a residência de Lorhany, não se confirmaram por nenhum outro elemento de prova nos autos, a não ser a palavra dos policiais. Vejamos.

Interrogada em juízo LORHANY BARBOSA SILVA negou que tenha praticado tráfico em associação. Nunca traficou na vida. Lorhany é um nome comum. Tem várias meninas trans que conhece que moram no centro com esse nome. Não sabe porque os policiais teriam dito que teria fornecido alguma coisa. Tinha um relacionamento afetivo casual (ficávamos) com o Tarcísio. Mas não sabia que ele usava entorpecente. Na época em que iniciaram o relacionamento ele fazia bico em uma lanchonete. Brigaram e falou para ele ir até sua casa pegar as coisas dele e deixar a chave na portaria. O relacionamento durou uns 30 dias mais ou menos. Nunca esteve no "Hotel Dela Rose". Lorhany é um nome comum. O funcionário do Hotel mencionou uma pessoa de nome Lorhany. Não era eu. Não sabe se Tarcísio se relacionava com outra pessoa de mesmo nome. Afirmou que não faria sentido pagar um hotel, gastar mais dinheiro, já que tinha seu apartamento. Não sabe porque Tarcísio teria dito que traficava com ela. Brigou com Tarcísio por motivos pessoais, porque ele estava distante. Tarcísio nunca usou droga na sua presença. Conseguiu alterar seu nome no na certidão de Batismo já consta LORHANY. Nunca esteve na comunidade parque do gato, não conhece esse lugar. É uma mulher transexual. No dia da prisão estava na casa do Pai de Santo. O Barracão era em Santana. Ia para lá com frequência. Não confessou o tráfico. Não foi levada até o hotel para que tentasse ser efetuado a reconhecimento. Foi levada direto para a delegacia no dia em que foi presa. Só conhecia Fernando (Nicássio), mais nada. Quando se prostituía usava o nome LORHANY BARBOSA. Tem bastante gente com esse nome. Não usa droga, não bebe, não usa entorpecente. Av. Duque de Caxias, nº 834 é o endereço da minha residência. Está presa tão somente em razão de seu nome.

Em relação a sua pessoa ainda, esclareceu que tem 36 anos de idade. É solteira. Não tem filhos. Estudou e quase terminou o ensino médio. Parou no terceiro ano por conta de trabalho. Tinha 34 anos quando parou de estudar. Quando chegou em São Paulo foi garota de programa. Participou do transcidadania do governo Haddad. Recebia uma bolsa de R\$ 980,00. Além disso trabalhou num programa da Santa Casa e recebia R\$ 1.500,00. Programa portadora do vírus do HIV – transamigas que tinha por finalidade auxiliar a adaptação de pessoas trans que tinham acabado de constatar que eram soro positivo. Pagava aluguel e mandava dinheiro para a mãe em Belém do Pará. Quando foi presa já tinha saído dos programas. Continuou com a escola e também se prostituía. Também fez bicos em festas como garçonete e recepcionista. Também trabalhou como agente SUAS. Quando foi presa estava apenas se prostituindo e fazendo bicos em festas. Auferia entre R\$ 2.500,00/3.500,00. Morava em casa alugada. Pagava R\$ 1.300,00. Ajudava a mãe apenas. Nunca foi processada antes.

Folha de Antecedentes (fls. 91/94) e Certidão do Distribuidor Criminal de LORHANY (fls. 66) vieram aos autos revelando a ausência de passagens e antecedentes.

Ainda a fls. 165 foi juntado aos autos a certidão de nascimento de LORHANY BARBOSA SILVA e a fls. 166 e 167 declarações de trabalho.

BEBEL SOARES DE SOUZA (nome social de ALISSON SOARES DE SOUZA), quanto aos fatos, confessou que portava 6 pinos de cocaína para seu uso, não estava associada nem vendendo drogas. Não conhece essas pessoas. A pessoa que está na imagem, de pé na esquina, foi quem me vendeu a droga. Não fui eu que vendi para ela. Eu comprei, descí a rua, entrei no bar e fui presa. Eu estava ali a passeio, me prostituindo também. A pessoa que me vendeu desapareceu. Não sou eu que estou na imagem mostrada na audiência.

NICASSIO MARINHO DA SILVA, em relação aos fatos confessou que portava 12 pinos de cocaína. Foi pegar a droga para ir numa festa com os amigos. Esclareceu que foi no Largo do Arouche pegar pó. Quando viu o traficante se assutou e sai correndo e os

policiais pegaram um monte de gente. Desde 2020 pega pó lá. Nunca traficou. Já aprontou muito na vida. Mas traficar, nunca traficou. Só usa cocaína. Já foi pego três vezes, no busca pó.

SÉRGIO DE SOUZA, em relação aos fatos, Sérgio negou o tráfico em associação. Esclareceu que estava indo em direção à estação República do metrô. Várias pessoas foram abordadas. Levaram para averiguação. Desde então, quase 10 meses está preso. Provavelmente porque já tem passagem. Não conhece os demais. Mais de 10 pessoas foram abordadas. Fizeram um paredão. Eles liberaram uns 6 ou 7. Não conhecia as pessoas. Estava vindo do bomprato para a estação da República. Ia para Santana. Morava em uma pensão lá. Pagava R\$ 150,00.

Em relação a sua pessoa disse que tem 31 anos de idade. É solteiro. Não tem filhos. Estudou até o segundo grau completo. Terminou com 19 anos. Já trabalhou de instrutor de boxe. Estava desempregado, havia uns dois anos. Fazia bicos de carga e descarga. Auferia cerca de R\$300,00 a R\$ 400,00 por semana. Mas era inconstante. Já foi processado antes. Por assalto. Foi condenado e pagou. Sua Certidão do Distribuidor Cível e Folha de Antecedentes também foram juntados nos autos (fls. 72/73 e fls. 83/85).

TARCISIO FERNANDO MOURA DA SILVA em relação aos fatos negou o tráfico em associação. Estava no centro. Tinha ido entrega uns Currículos. Desceu no Arouche para comprar pó. Comprou 5 papelotes e tinha R\$ 250,00 da sua rescisão de trabalho. Conhece a Lorhany de vista apenas. Não tem envolvimento com ela. Assim que pegou o pó, a polícia estava enquadrando muita gente. Ia voltar para Guarulhos onde mora, quando foi abordado pelos policiais. Nega que seja a pessoa que aparece no vídeo que os policiais exibiram na audiência anterior. Negou que tivesse levado os policiais. Chegou a ter relação amorosa com a Lorhany, mas não chegaram a morar juntos. Conversavam. Mas era só esse contato mesmo. Chegou a pagar por programa. Não tinha chave do apartamento dela. Não subiu no apartamento dela. Não confessou nada para os policiais. Não conhecia o "Hotel Dela Rose" antes de ter sido levado até lá pelos policiais. Não subiu no hotel. Tinha mais duas travestis que chamavam Lorhany no local. So usava cocaína. Começou a usar mais ou menos há um ano antes de ser preso.

As testemunhas arroladas pela defesa de TARCISIO nada esclareceram sobre os fatos.

Maria Rejane Moura Silva, mãe de Tarcisio, ouvida independente de compromisso disse que Tarcisio sempre trabalhou, quando ficava desempregado fazia bico para ajudar em casa e as filhas. É um bom filho e um bom pai. Ele já trabalhou na SL presente, na Bauducco e em mais outra empresa. Quando foi preso, ele estava trabalhando. Ele sempre morou em Guarulhos. Meu filho nunca se envolveu com más companhias ou coisas escusas.

Já Robson de Oliveira Macedo, também ouvido independente de compromisso, disse que é amigo de Tarcisio pois ele já manteve relacionamento com sua irmã. Afirmou, em síntese, que conhece ele há mais de 10 anos. Ele sempre trabalhou, metalúrgico, transportes, inclusive já trabalharam na mesma empresa. Tinha costume de frequentar a casa de Tarcisio quando ele tinha relacionamento com a sua irmã. Faz três anos que eles se separaram. Nunca soube de seu envolvimento com droga, ou outros assuntos irregulares. Ele é bom pai, presente para a filha, nunca deixou faltar nada. Não sabe do envolvimento de Tarcisio e Lorhany.

Essas são as provas colhidas nos autos e elas não permitem a prolação de uma sentença condenatória de forma segura.

É de se observar que, apesar da requisição ao IC (fls. 20) para realização de perícia do entorpecente encontrado dentro do quarto do hotel, dizer que teria sido encontrado no quarto alugado por LORHANY, não há nos autos, prova segura e que

permitisse tal afirmação.

Há apenas, o depoimento dos policiais falando sobre confissões informais e apesar da notícia de existência de câmeras de vídeo do hotel e livro de registro, nenhuma dessas provas veio aos autos.

Não bastasse isso, a única testemunha, FAGNER JOSÉ, que poderia ligar a pessoa de Lorhany ao Hotel, fazendo com que a versão da acusada no sentido de que não seria sua pessoa, mas talvez outra, com o mesmo nome, não procedeu ao reconhecimento.

Diga-se ainda que apesar de o depoimento dos policiais ter afirmado que TARCISIO, quando preso teria dito que o celular que possuía seria de Lorhany, o laudo pericial de fls. 303/307 não pode confirmar essa situação.

Assim, no que diz respeito ao tráfico em associação, as confissões informais não se confirmaram, não se produziu prova segura de que a acusada Lorhany é quem alugava o quarto de hotel e que o celular supostamente utilizado no tráfico por Tarcisio, seria de Lorhany.

Assim, diante desses elementos, concluo que só o depoimento dos policiais não é suficiente para possibilitar a condenação de LORHANY por tráfico em associação.

Prosseguindo, observo que no que diz respeito ao testemunho dos policiais, não foram suficientemente corroborados pelas filmagens juntadas aos autos.

De acordo com o depoimento dos policiais, tudo o que foi filmado foi juntado ao processo e pode ser acessado pelo link de fls. 58.

Deve-se ressaltar antes de acessar o teor das filmagens, que de acordo com o testemunho do policial Sandro, as filmagens foram tidas por suficientes para comprovação dos fatos a ponto de dispensar a necessidade de buscar outras testemunhas e apesar de terem sido parabenizados no dia e momento da prisão em flagrante segundo afirmou.

Pois bem, em relação ao conteúdo das filmagens, apesar de terem os policiais afirmado que puderam ver o acusado SÉRGIO, que seria o olheiro constantemente conversando com os demais e se deslocando por toda a região, sempre observando a movimentação local, não há nenhuma cena filmada da suposta atuação criminosa de Sérgio.

Some-se a isto, o fato de que SÉRGIO não foi encontrado com celular ou qualquer outro petrecho que o auxiliasse na sua missão de olheiro do tráfico.

Assim, diante desses elementos, concluo que só o depoimento dos policiais e mais o que puderam descrever como o que seria sua atuação, não é suficiente para possibilitar a condenação de SÉRGIO por tráfico em associação.

Seguindo na análise das provas, quanto ao teor dos vídeos, o primeiro deles, mostra uma pessoa que vai até próximo de uma mureta baixa, se inclina para baixo, depois levanta e dali se afasta.

O outro vídeo, supostamente mostra BEBEL (ela não admite seja a sua pessoa) dando voltas em uma esquina, quando passa um outro rapaz de bicicleta, aparentemente inicia uma conversa com ela, tiram e põe coisas no bolso quando se aproxima mais uma pessoa, que supostamente seria Nicasso e após alguns instantes eles saem afastando-se uns dos outros.

Em relação ao primeiro vídeo, demonstraria a suposta atuação de TARCISIO como gerente do tráfico em associação. Ocorre que a cena apenas demonstra uma pessoa que

vai até uma mureta se abaixa, faz não se sabe bem o que e a filmagem é interrompida antes do momento da suposta entrega para os vendedores.

Inegável que a filmagem dessa entrega para comprovação da imputação seria de suma importância. Contudo, não foi registrada.

É certo que TARCISIO acabou por admitir que a droga encontrada na mureta, 5 papérolas dentro de um maço de cigarro eram de sua propriedade, contudo isso não é suficiente para descartar a sua versão de que possuía a droga para seu consumo e para ter por comprovado o tráfico, por ele negado.

Em relação a todas as outras confissões informais a ele atribuídas, quanto ao tráfico, quanto à associação com Lorhany, quanto à indicação do hotel e do endereço dela, igualmente, não se confirmaram. Ele as negou e os policiais não conseguiram reunir outros elementos que viessem a corroborar suas afirmações.

Prosseguindo, a cena que registra uma suposta venda por parte dos acusados Nicasso e Bebel, a imagem não é clara o suficiente para os identificar e para identificar a venda. Em parte porque a qualidade não é boa e em parte porque há um poste no meio que impede ver quem entrega o que para quem e se entrega.

Não é possível ver a venda de modo que apesar de Nicasso e Bebel terem sido surpreendidos com 12 e 6 papérolas de cocaína respectivamente, não é possível descartar a sua versão de que estavam com a droga para consumo próprio.

Some-se à versão dos acusados, o fato de que não foram encontrados com eles nenhum dinheiro, nenhuma anotação e a quantia não é expressiva a ponto de permitir concluir pelo tráfico sem sombra de dúvidas.

Assiste razão à defesa, portanto, quando afirma que pelo quanto restou demonstrados nos autos houve pouca investigação prévia que pudesse trazer elementos suficientes para embasar a imputação de tráfico e associação.

O crime de associação previsto no art. 35 da lei 11.343/06, não veio devidamente comprovado nos autos. Não obstante o esforço e do representante do Ministério Público que atua perante este juízo, para a caracterização deste delito a lei prevê a necessidade de ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.

E no caso em tela, não há nos autos qualquer elemento de prova de que os acusados concertaram suas vontades e se compuseram em organização estável e duradoura com terceiras pessoas, ou que se associaram para praticar o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse ponto, ressalta-se que para que alguém responda por este crime autônomo, são necessários os seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; e d) finalidade de traficar tóxicos.

Como ensina Vicente Greco Filho, a associação criminosa exige a presença do ânimo associativo, ou seja, "de um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado". (Tóxicos, 1979, p.104).

Nem mesmo em relação ao tráfico há prova suficiente, como já se analisou.

De início, observa-se que a quantidade de droga apreendida com Bebel, Nicasso e Tarcisio é congruente com a de um usuário. Ainda, é de se observar que não fora encontrada variedade de drogas, mas apenas um tipo de entorpecente. Por fim, a forma como estavam acondicionadas é condizente com a de quem adquire para consumo. Assim, só os depoimentos dos policiais na hipótese dos autos não se revelou suficiente para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06.

É certo, outrossim, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais

nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos, no entanto, no caso dos autos é possível depreender que se basearam em suposições e descuidaram de reunir outros elementos que corroborassem aquilo que puderam ver no momento. Se não devem ser desconsideradas de um lado, tão pouco devem ser tidas por provas absolutas, a prescindir de outros elementos que as confirmem, tanto mais para sustentar uma imputação de associação para o tráfico.

Ressalte-se, outrossim, que, em que pese não haver nos autos indícios que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra os acusados, a investigação foi breve, ficaram em campanha entre 30 a 40 minutos, no máximo uma hora, sem nunca antes terem estado no local e descuidaram de obter outros elementos de prova para corroborar suas conclusões.

O fato de terem chegado ao endereço de Lorhany tão pouco é suficiente para a comprovação da associação para tráfico. A uma porque o tráfico não restou devidamente demonstrado. A dois porque mantinham um relacionamento afetivo ainda que breve e casual e seria comum ele soubesse seu endereço. A três porque o vínculo de Lorhany com o Hotel não restou devidamente demonstrado.

É de se indagar, também, porque não teria sido detida a motocicleta de Lorhany se a denúncia existente dizia que ela era utilizada para a prática da traficância.

Enfim, diante de todas essas circunstâncias, possível concluir unicamente que restou efetivamente comprovado que NICASSIO tinha 12 papelotes de cocaína consigo, BEBE (ALISSON) tinha 06 papelotes de cocaína consigo e TARCISIO tinha 05 papelotes de cocaína e R\$ 190,00 em dinheiro consigo.

Em outras palavras, a prova produzida pela acusação não foi suficiente para colmatar a convicção sobre a prática do crime de tráfico de drogas e portanto, a condenação pela prática da infração do artigo 28 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Nesse passo, não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06 uma vez que de acordo com a jurisprudência dominante o tipo protege para além do individuo a saúde pública.

Desta feita é que, em relação a Lorhany e Sérgio impõe-se a absolvição e em relação a Bebel (Alisson), Nicasso e Tarcisio deve haver a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Portanto, passo à dosimetria das penas.

BEBEL SOARES DE SOUZA (nome social de ALISSON SOARES DE SOUZA), esclareceu que tem 31 anos de idade. É solteira. Não tem filhos. Estudou até a 5ª série. Nasceu em Aracaju, Sergipe. Parou de estudar porque entrou na prostituição muito cedo, com 16 anos. Até um pouco antes. Trabalhava num salão de cabeleireiro e como prostituta. Sua renda mensal era de aproximadamente R\$ 2.000,00. Pagava R\$ 500,00 de aluguel. Já foi processada por furto e foi absolvida e por uso de entorpecente. Sua Folha de Antecedentes (fls. 89/90) e Certidão do Distribuidor (fls. 67/68) foram juntadas aos autos e demonstram que Bebel teve realmente uma denúncia pelo artigo 28 da lei 11.343/06, em relação a qual não houve condenação e uma condenação por furto tentado, que foi anulada em grau de recurso.

Nos termos do que dispõe a artigo 28, inciso III, e §3º da Lei 11.343/06, considerando sobretudo a quantidade de droga apreendida com a acusada, condeno-a à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual "será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas" (artigo 28, § 5º, da Lei 11.343/06).

NICASSIO MARINHO DA SILVA disse que tem 32 anos de idade. É casado. Tem uma filha de 15 anos. Estudou até a 7ª serie e parou porque começou a fazer coisa errada,

fumar maconha com os colegas. Tinha 20 anos de idade quando parou. Trabalha na galeria do Rock. É tatuador. Trabalha na Carol Tatoos. Auferia por dia cerca de R\$ 1.000,00. Ganhava bastante no mês. Já foi preso por roubo, quando saiu em 2020 a minha prima trabalhava lá e eu já tinha uma noção e comecei a trabalhar lá. Sua Certidão do Distribuidor (fls. 69/71) e Folha de Antecedentes foram juntados aos autos (fls.75/82), tendo restado demonstrado que possui antecedente criminal (v. condenação definitiva do processo n. 0086676-83.2009.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal fls. 69) e é reincidente (v. certidão de fls. 69/70, processo n. 0106935-60.2013.8.26.0050, da 16ª Vara Criminal da Capital).

Nos termos do que dispõe a artigo 28, inciso III e §4º da Lei 11.343/06, considerando sobretudo a pequena quantidade de droga apreendida com o acusado, condeno-o à pena de 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual "será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas" (artigo 28, § 5º, da Lei 11.343/06). TARCISIO FERNANDO MOURA DA SILVA disse que tem 33 anos de idade. É solteiro. Tem duas filhas, de 7 e 11 anos de idade. Estudou até oitava série. Parou para trabalhar. Teve filho cedo. Estava com 23 anos. Trabalhou por quase quatro anos como auxiliar de produção, na Bauducco. Já trabalhou como vendedor. Já trabalhou numa metalúrgica. O último emprego foi numa empresa de alimentos. Tinha carteira assinada, recebia salário de R\$ 1.470,00. Era auxiliar de produção. Morava com a mãe, em casa alugada por R\$ 500,00. Ajudava a mãe além das filhas por pensão combinada com a mãe. Nunca foi processado antes. A sua Certidão do Distribuidor Cível (fls. 74) e sua Folha de Antecedentes (fls. 86/88) foram juntadas aos autos e demonstraram ser primário.

Nos termos do que dispõe a artigo 28, inciso III e §3º, da Lei 11.343/06, considerando sobretudo a pequena quantidade de droga apreendida com o acusado, condeno-o à pena de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual "será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas" (artigo 28, § 5º, da Lei 11.343/06). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER os acusados LORHANY BARBOSA SILVA (certidão de nascimento fls. 165) e SÉRGIO DE SOUZA da imputação de ter praticado os crimes previstos nos tipos penais dos artigos 33 caput e 35 da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o acusado BEBEL SOARES DE SOUZA (nome social de ALISSON SOARES DE SOUZA), como incurso no 28 da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena nos termos do artigo 28, inciso III, e §3º da Lei 11.343/06, de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual "será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas" (artigo 28, § 5º, da Lei 11.343/06); NICASSIO MARINHO DA SILVA como incurso no 28 da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena nos termos do artigo 28, inciso III, e §3º da Lei 11.343/06, de 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual "será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas" (artigo 28, § 5º, da Lei 11.343/06) e; TARCISIO FERNANDO MOURA DA SILVA como incurso no 28 da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena nos termos do artigo 28, inciso III, e §3º da Lei 11.343/06, de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual "será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da

prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas" (artigo 28, § 5º, da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Após o trânsito em julgado determino a devolução dos celulares apreendidos de propriedade de Lorhany e Tarcisio. Ainda, determino a devolução do valor de R\$ 190,00 apreendido com Tarcisio, após o trânsito em julgado, tudo conforme conforme o artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, pois não há qualquer evidência de que não sejam pessoas com hipossuficiência econômica como declinaram.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, atualizando-se o SAJPG5.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA